



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעים	1	גיל אסקין הלוי,
	2	אנדרו הלוי,
		באמצעות ב"כ: עו"ד סלע-פלקס סימה
נגד		
נתבעים	1	ירון עזרן, אחר
		נעמי 7, ירושלים
	2	חיים צבי לורנץ,
		נעמי 7, ירושלים
	3	גלי בורמן,
		נעמי 7, ירושלים
	4	שירל חנה כהן בורמן (נמחקה),
		נעמי 7, ירושלים
	5	מטילדה ארזי,
		באמצעות ב"כ: עו"ד סיגלית שאלתיאל
		בן הלל 14, ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם קיימות הסכמות מחייבות ובלתי הדירות בין בעלי הדירות בבית המשותף לחלוקת השימוש בשטחים המשותפים.

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף שברחוב נעמי 7 בירושלים הידוע כגוש 30511 חלקה 15 (להלן – הבית המשותף). לבית המשותף אין תקנון מוסכם, ועל כן חל עליו התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין).

2. בבית המשותף קיימת קומת מרתף, קומת קרקע ושתי קומות נוספות. בפועל קיימות בבית המשותף 5 דירות, אולם 7 תתי חלקות (אחת מהדירות היא 3 תתי חלקות שאוחדו לדירה אחת). התובעים הם בעלי הזכויות בדירה בקומה השנייה של הבית המשותף הרשומה כתת חלקה 6, הנתבע 1 הוא בעל דירה בקומת המרתף הרשומה כתת חלקה 1, הנתבע 2 הוא בעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירה בקומת הקרקע (בנסח הרישום רשומה כקומת מרתף) הרשומה כתת חלקה 2, והנתבעת 3 היא בעלת תתי חלקות 3-5 שכולן אוחדו לדירה אחת בקומה הראשונה. הנתבעת 5 היא בעלת דירה בקומה השנייה הרשומה כתת חלקה 7.

3. באופן פיזי, קיימים שערים וגדרות בחצר הבית המשותף, התוחמים 3 חצרות במפלסים שונים. 3 החצרות הסמוכות לדירות הנתבעים 1-3 נמצאות כל אחת בשימוש ייחודי של כל אחת מדירות הנתבעים. בנוסף, קיימות מדרגות מתוך דירת התובעים המובילות לגג שמעל דירתם. על הגג, בחלק הנמצא מעל דירת התובעים, הותקנו פרגולה ודק על ידי התובעים. מהגג הנמצא מעל דירת התובעים ודירת הנתבעת 5 קיימת אפשרות להגיע לגג נוסף (להלן – הגג העליון) עליו נמצאים כיום דודי שמש של חלק מבעלי הדירות.

עיקר טענות התובעים

4. לטענת התובעים לא קיימות הסכמות בין בעלי הדירות לעניין חלוקת הרכוש המשותף, ובכלל זאת לא קיימות הסכמות בכתב וכן לא ניתן ללמוד על הסכמות כאמור מהראיות שהוגשו. לטענתם היו ניסיונות בעבר להסדיר את חלוקת הרכוש המשותף אולם אלו לא צלחו. לטענתם, הנתבע 1 אף התנגד בעבר לעבודות שביצעו התובעים בגג בטענה שהם מספחים לעצמם רכוש משותף, אולם כעת טוען שזכויות השימוש בגג שייכות להם בשל החלוקה הנתענת.

5. לטענתם, אף אם הייתה הסכמה הרי שהם רשאים לחזור בהם ממנה, שכן לא בוצעו השקעות משמעותיות על ידי הנתבעים בחצרות הסמוכות לדירתם, ולא מתקיימות הנסיבות החריגות המונעות חזרה מהסכמה כאמור.

6. התובעים מבקשים שהשטח המשותף יהיה נגיש באופן מלא ולצורך כך גם יהרסו קירות ושערים. לטענתם, הנתבעים לא הוכיחו שמדובר בהריסת קירות תמך. בנוסף מבקשים התובעים שהנתבעים יסירו כל מבנה גדר קיר או שער שנבנו בשטחים המשותפים המפריעים לשימוש יתר בעלי הדירות.

טענות הנתבעת 5

7. הנתבעת 5, שדירתה, כמו דירת הנתבעים, נמצאת גם היא בקומה השנייה, ואין חצר הסמוכה לדירתה, מבקשת שסעדי התביעה יתקבלו. לטענתה לא קיים הסכם חתום בין בעלי הדירות. לטענתה לא עשתה שימוש ייחודי בגג. לטענתה, גם לצורך שימוש ייחודי ברכוש משותף נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות והסכמה כאמור צריכה להיות מפורשת.

8. לטענתה, באף אחד מהמסמכים שהציגו הנתבעים 1-3 אין הסכמה של כל בעלי הדירות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. לטענתה, הנטל להוכיח זכות לשימוש ייחודי הוא על המבקשים זאת, והנטל לא הורם.

9. לטענתה, פרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2002 נוסח כך שכוונתו שמירה על מצב קיים. לטענתה, לאחריו בוצעו שינויים מהותיים במצב הקיים. כחלק מכך נוספו גדרות ושערים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שלא היו בעבר. לנתבעת 5 גם טענות כלפי הנתבעת 3 על שינויים שביצעה לטענתה בקירות החיצוניים המהווים רכוש משותף.

10. הנתבעים 1-3 מעולם לא התייחסו לחלק מהגג כשייך לנתבעת 5. לטענתה, עשרות שנים היו דודי שמש של הנתבעים 2-3 על הגג התחתון, אשר נטען לגביו שהוא בשימוש ייחודי שלה ושל התובעים. כמו כן היו שם צינורות של כל בעלי הדירות. בנוסף, הנתבעים 1-3 שילמו על זיפות הגג התחתון. לטענתה, הנתבע 1 התלונן על סיפוח מצד התובעים בנוגע לגג שזכתה הוא טוען שהוא בשימוש הייחודי.

11. לטענתה, ביקשה בשנים 2018, 2019 לדון בשימוש בשטחים המשותפים.

12. עוד לטענתה, גם אם הייתה קיימת הסכמה לשימוש הייחודי הרי שניתן לחזור מהסכמה זו.

13. לטענתה, השקעות הנתבע 1 נועדו לשם הרחבת דירתו ולא לשם קבלת שימוש ייחודי בגינה.

14. לטענתה, חישוב היחס בין הרכוש המשותף המנוצל על ידי דירות הנתבעים לבין שטחי דירות הנתבעים לא לקח בחשבון שטח מחדר המדרגות שסיפחה הנתבעת 3.

עיקר טענות הנתבעים 1-3

15. לטענת הנתבעים 1-3, קיימת הסכמה של עשרות שנים לעניין שימוש ייחודי של כל אחד מבעלי הדירות בשטח הסמוך לדירתו, וכן היו קיימים גדרות ושערים עשרות שנים. כמו כן בפועל עשו בעלי הדירות שימוש ייחודי בשטחים כאמור במשך עשרות שנים.

16. לטענתם, בתחילת שנות ה-2000 הנתבע 1 ביצע עבודות על חשבוננו ברכוש המשותף בהסכמת 4/5 מבעלי הדירות, אשר כללו את כל בעלי הדירות למעט קודמיהם של התובעים, בתמורה להסכמתם להצמדות של רכוש משותף לדירתו אשר כללו שטח שנחפר מתחת לדירתו. קודמיהם של התובעים הגישו התנגדות להיתר שביקש הנתבע 1 בנוגע להרחבת דירתו, אולם התנגדותם נדחתה בשנת 2004 ומאז לא פעלו בעניין. העבודות בוצעו על ידי הנתבע 1 לרבות בנייה מחדש של קירות תמך ושיפוץ שביל הכניסה לבניין.

17. לטענתם, התובעים רכשו את הדירה לאחר השלמת העבודות בשנת 2007 ובמשך עשור לא טענו דבר בעניין. כמו כן התובעים עצמם ביצעו עבודות על גג הבית המשותף והשתמשו במדרגות שנפרצו מדירתם לגג. בשלב מסוים ביקשו להצמיד את הגג ואת זכויות הבניה לדירתם וכאשר בעלי הדירות האחרים סרבו, ביקשו לשנות את הסטאטוס קוו הקיים.

18. לטענתם, התובעים הגישו את התביעה בחוסר תום לב שכן הם עצמם עושים שימוש ייחודי בגג ובמחסן הסמוך לכניסה לגג. כמו כן עלה כי בניגוד להצהרותיהם שאין להם כוונה לבצע עבודות נוספות על הגג, פרסמו פוסט לבניית דק נוסף על הגג. בנוסף, התובעים ידעו בעת שרכשו את דירתם על קירות התמך השער ומבנה העזר הקיים בבית המשותף. לטענתם, לתובעים שיקולים זרים בהגשת התביעה, והיא כסות להשגת מטרות פסולות אחרות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. לטענתם אין כל הצדקה להריסת קירות התמך, דבר שיכול לגרום לנזקים. באשר למבנה העזר, הרי שזה קיים לפחות 45 שנים.

20. באשר לסעדים הנוגעים לשימוש ברכוש המשותף, לטענת הנתבעים 1-3 התובעים ביקשו סעדים ספציפיים של הריסת גדרות ושערים שאין מקום לתתם, וכן סעדים כלליים ומעורפלים בנוגע לשימוש ברכוש המשותף, ובהיעדר סעדים מוגדרים נוספים בעניין זה, אין מקום לתת סעדים שלא התבקשו באופן מפורש.

21. לטענתם, ההסכמה לחלוקת השימוש ברכוש המשותף היא בלתי הדירה, וחלה גם על בעלי דירות שבאו בנעליהם של בעלי דירות שנתנו את ההסכמה. הסכמה זו באה לידי ביטוי גם בפרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2002. אמנם קודמיהם של התובעים לא חתמו על אותו פרוטוקול אבל גם לא התנגדו לאותה הסכמה, ואף פעלו על פיה שכן פרצו פתח לגג ובנו מדרגות מדירתם לגג.

22. לטענתם, התובעים נמנעו מלזמן את בעלי הדירה שקדמו להם לדיון ובכך יש חזקה שעדות כזו ככל שהייתה ניתנת הייתה פועלת לרעתם.

23. לטענתם, התובעים אינם רשאים לחזור בהם כיום מההסכמות שנתנו לעניין חלוקת הרכוש המשותף לאור שיקולי צדק ותום לב, כוונות הצדדים, והסתמכות הנתבעים אשר ביצעו השקעות בחצרות הסמוכות לדירותיהם.

החליך

24. בהליך התנהל דיון מקדמי, וכן בוצע ביקור במקום, במסגרתו נעשה סיור בחצרות הסובבות את הבית המשותף ובגג.

25. ביום 25.10.2022 התקיימה ישיבת הוכחות. מטעם התובעים העידו התובעים עצמם וכן נחקרה השמאית מרגלית מור על חוות דעת שנתנה. מטעם הנתבעים העידו הנתבעים 1-3 והנתבעת 5, לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

דיון והכרעה

קיומו של הסכם בין בעלי הדירות לעניין שימוש ייחודי ברכוש המשותף

26. אין מחלוקת כי שטחי החצרות אינם צמודים קניינית לדירות הנתבעים. הצמדה קניינית של חצר המהווה רכוש משותף צריכה להיות מבוססת על הוראת תקנון הבית המשותף, כאמור בסעיף 55(ג) **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – **חוק המקרקעין**) או על החלטה של כל בעלי הדירות כאמור בסעיף 62(א) **לחוק המקרקעין**. הסכמות כל בעלי הדירות לביצוע הצמדה קניינית צריכות להיות מפורשות [ר' ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי-רפול**, נ"ד(3) 389, (2000) בעמ' 394], ומשנרשמו בתקנון כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן (סעיף 62(ג) **לחוק המקרקעין**). הסכמות כאמור לא קיימות בענייננו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. עם זאת, בעלי הדירות יכולים להסכים על מתן זכות שימוש ייחודית למי מהם ברכוש המשותף. זכות כאמור אינה זכות קניינית, אולם נדרשת לכך הסכמה של כל בעלי הדירות [ר' ע"א 2525/92 **ראוכברג נ' עיריית רמת גן**, מז (5) 850; רע"א 698/86 **בן צור נ' נעים ששון** (נבו 23.7.1987)].

בשונה מהסכמה למתן זכות קניינית, הטעונה מסמך בכתב, הסכמה לעניין זכות שימוש ייחודית יכולה להינתן גם בעל פה, ואף להילמד מהנסיבות, אולם היא חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות [ר' ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו (3) 78, (1982) בעמ' 83 (להלן – **עניין כליפא**)].

28. בהתקיים תנאים מסוימים, זכות כאמור יכולה לחייב גם אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן, אף שלא נרשמה (ר' עניין **כליפא**, ע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד לו (2) 497, 502; ע"א (מחוזי חיפה) 1020/03 **בובליל נ' שטיינר** (נבו 25.02.2004)).

29. בענייננו, אין מחלוקת שלא קיים הסכם בכתב לעניין חלוקת השטחים המשותפים בין בעלי הדירות בבית המשותף, אלא שלטענת הנתבעים בנסיבות העניין הוכח שקיימת הסכמה לחלוקה כאמור בין בעלי הדירות, המחייבת גם את התובעים. לפיכך יש לבחון האם הנסיבות כפי שעלו מראיות הצדדים מבססות הסכמה כזו. מכיוון שאין מחלוקת ששטחי החצרות האמורים רשומים כרכוש משותף, הרי שהנטל להוכיח קיומה של הסכמה כאמור מוטל על הנתבעים.

30. אין מחלוקת שהנתבעים רכשו את הזכויות בדירותיהם לפני עשרות שנים, והאחרון שבהם, הנתבע 1, רכש את זכויותיו בדירה בשנת 2000. התובעים רכשו את זכויותיהם בדירתם בשנת 2007 ממשפ' קולודני, בעלי הדירה הקודמים (להלן – קולודני).

31. מראיות הנתבעים 1-3 עולה שבבית המשותף הייתה בעיית רטיבות חמורה שפגעה ביסודותיו וגרמה להיחלשות האבן, ובין היתר נגרמה נסיגת קרקע על דירת הנתבע 1 שקיעה של חדר המדרגות, התפוררות טיח, חלודה בקורות הפלדה ועוד, אשר הביאו לצורך לבצע שיפוץ יסודי, לרבות חיזוק קונסטרוקטיבי של הבנין (ר' פירוט בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 1.5.2002, נספח 5 לתצהיר הנתבע 1 עליו חתומים כל בעלי הדירות למעט קולודני). בעקבות כך, הוסכם על בעלי הדירות, למעט קולודני, שהנתבע 1 יבצע עבודות חיזוק ושיפוץ של הבנין על חשבונו, ובתמורה יוצמד לשטח דירתו שטח בור המים שהיה סמוך אליה. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בירושלים אישרה היתר בניה לביצוע העבודות למרות התנגדותו של קולודני, ובהמשך ביצע הנתבע 1, עזרן, על חשבונו את עבודות השיפוץ בבית המשותף שכללו חיזוק יסודות המבנה, שיפוץ שביל הכניסה, עיבוי קירות תמך, החלפת תשתיות מים וביוב ועוד, וכן ביצע עבודות חפירה בבור המים וביטל אותו תוך הרחבת דירתו. העבודות האמורות הסתיימו בשנת 2005, עוד לפני שרכשו התובעים את זכויותיהם בדירתם, כך שהתובעים לא היו מעורבים בהשתלשלות עניינים זו (ר' סעיפים 18-27 לתצהיר הנתבע 1). הפירוט שניתן על ידי הנתבעים 1-3 בתצהיריהם בעניינים אלו לא נסתר, ונתמך בין היתר בפרוטוקול אסיפת בעלי הדירות המוזכר לעיל, בטופס הסמכת בעלי הדירות (למעט קולודני) לביצוע העבודות נספח 6 לתצהיר הנתבע 1, ובהחלטת הוועדה המחוזית בערר שהגישו קולודני לעניין ההיתר נספח 7 לתצהיר הנתבע 1.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. מבחינת המצב הפיזי של הגג והחצרות, אין מחלוקת שבעת שרכשו התובעים את דירתם בשנת 2007, הגדרות והשערים, התוחמים את החצרות הסמוכות לדירות הנתבעים 1-3, היו קיימים. בנוסף, קיים גרם מדרגות מתוך דירת התובעים אל הגג שמעל דירתם, המוביל לפתח שנפרץ מתוך הדירה לגג, בעקבות עבודות שביצעו קולודני בעת שהיו בעלי הדירה. בשנת 2020 בנו התובעים פרגולה ודק על גבי הגג, הניחו שולחן וכסאות כדי לאפשר לעצמם שימוש בגג וכן הגביהו את הגדר המקיפה חלק מהגג והניחו על הגג ארון אחסון (סעיף 28 לתצהיר התובע).

33. פרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 1.5.2002 (נספח 5 לתצהיר הנתבע 1) עוסק בהסכמת בעלי הדירות, למעט קולודני, לביצוע העבודות על חשבון הנתבע 1 בתמורה להרחבת דירתו לכיוון בור המים. בפרוטוקול נכתב בסעיף 6 שמוסכם שכל האמור אינו בא לפגוע בחלוקת השטחים המשותפים לפיה הגינה הדרומית בשימוש לורנץ (הנתבע 2), הגינה הצפונית בשימוש בורמן (הנתבעת 3), הגינה המזרחית בשימוש עזרן (הנתבע 1), שטח הגג מעל דירת קולודני בשימוש קולודני באופן יחסי לשטח הדירה ושטח הגג מעל ארזי (הנתבעת 5) בשימוש ארזי באופן יחסי לשטח הדירה. הפרוטוקול חתום על ידי כל בעלי הדירות דאז, כולל הנתבעת 5, למעט קולודני. אין מחלוקת שאותן חצרות נשוא הפרוטוקול הן החצרות נשוא הליך זה, אם כי חלו בהן שינויים מסוימים בעקבות העבודות שביצע הנתבע 1.

34. מהפרוטוקול האמור עולה שהייתה שלכל הפחות הייתה הסכמה מוקדמת, בין כל הנתבעים, לרבות הנתבעת 5, שהפרוטוקול הביא אותה לידי ביטוי בכתב, באשר לחלוקת השימוש בחצרות ובגג המשותף.

35. באשר לקולודני לא עולה מהפרוטוקול שהסכים לכך, משום שלא חתם עליו, אך מראיות אחרות עולה שגם קולודני הסכים לחלוקת השימוש כאמור.

ראשית, הסיבה העיקרית לכך שלא חתם על הפרוטוקול היא היעדר הסכמתו לכך שהנתבע 1 ישפץ את הבית המשותף ובתמורה ירחיב את דירתו על חשבון בור המים, שכן זה העניין שנדון באותה האסיפה, בעוד שנושא חלוקת השימוש צוין בפרוטוקול כעניין שהיה קיים קודם לכן ואין בהסכמות נשוא הפרוטוקול כדי לשנות אותו. אף שקולודני נקט בהליכים מול ועדות התכנון כלפי הנתבע 1 כדי למנוע את ביצוע ההחלטה שהתקבלה באותה אסיפה, לא הוגשה כל ראיה המצביעה על התנגדותו לחלוקת השימוש ברכוש המשותף כפי שהיא באה לידי ביטוי באותו פרוטוקול, אף לא במסגרת פניה כלשהי לבעלי הדירות האחרים.

שנית, שנים קודם לכן, ביום 4.7.1989 חתמו קולודני על הסכם עם הנתבעת 3 (נספח 2 לתצהיר הנתבעת 3) על פיו שטח הגג יהיה לשימושם הבלעדי של משפחת קולודני כולל שיפוץ, רצוף, בניית פרגולה, תאורה וגינון, ושטח הגינה שאינו כולל את אזור הכניסה לבניין יהיה בשימוש הנתבעת 3. הנתבעת 3 הסבירה בחקירתה הנגדית את הסיבה לחתימת המסמך בשנת 1989 למרות שההסכמות היו קיימות לטענתה גם קודם לכן, ואת הסיבה לכך שנחתם רק עם קולודני. על פי ההסבר שנתנה, ההסכם נחתם לאור התנגדות שהייתה למשפ' קולודני לשינויים בנוגעים לכניסה לבניין לכיוון חצרם שהיו מוסכמים על יתר בעלי הדירות. הסבר זה עומד בקנה אחד עם האמור בפרוטוקול הישיבה מיום 1.5.2002 אודות ההסכמות לחלוקת השימוש שהיו קיימות קודם לכן, שכן יתר בעלי הדירות, שההסכם ממילא המשיכו לנהוג על פי ההסכמה הקיימת (פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 20 שורות 29-43, עמוד 21 שורות 14-6). אוסיף שאין בעובדה שהנתבעת 3 נדרשה להסכמת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קולודני לביצוע השינויים כדי להראות שלא הייתה קיימת לה זכות לשימוש ייחודי בחצר קודם לכן, אלא לכל היותר שהיה צורך להסדיר היבטים בנוגע לאפשרות לבצע שינויים באותם שטחים שבשימוש ייחודי.

שלישית, התנהלות קולודני בכך שבנו בתוך דירתם מדרגות המובילות לגג שמעל דירתם ופרצו פתח לגג, מצביעה על כך שראו עצמם כבעלי זכות שימוש ייחודית בגג. הדבר מתחזק גם מתמונות שצורפו כנספח 3 לתצהיר הנתבע 1, בהם מצולם שטח הגג בזמן שהדירה הייתה בבעלות קולודני, ונצפה שהוא כלל גדר מתכת שהפרידה בין 2 חלקים של הגג (זה שהיה בשימוש קולודני לבין שטח שעל פי הנטען היה בשימוש של הנתבעת 5, ארזי) וכן כלל בחלק שהיה בשימוש קולודני, יריעת בד תלויה שהסתירה את הנעשה באזור שבשימוש קולודני.

36. מתצהירי הנתבעים 1-3 עולה שההסכמה האמורה, שבאה לידי ביטוי בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 1.5.2002, נהגה עשרות שנים, מאז שרכשו זכויותיהם בדירות. התובעים מצדם לא היו בעלי זכויות בדירה עד לשנת 2007, ולא הייתה להם ידיעה אישית אודות התנהלות בעלי הדירות לפני שרכשו את דירתם, והם לא זימנו עדים מטעמם להעיד על כך. מחקירת הנתבע 2 הראשון מבין הנתבעים שרכש את דירתו, בשנת 1965, עלה שבעבר לא הועלו טענות של מי מבעלי הדירות בנוגע לחלוקה הנוהגת, כאשר בתחילת הדרך, לאחר שרכש את דירתו, למעשה כל אזור הקדמי של הבית המשותף היה בשימוש, אולם כבר בעת שרכש את דירתו הסכים לשינויים שחלו זמן לא רב לאחר מכן, במיקום הכניסה לבית המשותף ובבית המשותף עצמו, אשר צמצמו שטח החצר שבשימוש (ר' פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 14 שורות 34-7).

37. התובעים עצמם אמנם רכשו את הדירה רק בשנת 2007, אולם כבר בעת הרכישה היו השערים וגדרות הקיימים כיום סביב החצרות שבשימוש הנתבעים 1-3, וכן היה קיים פתח לגג מדירתם וגרם מדרגות העולה אליו. בשנת 2020 התקינו התובעים כאמור דק ופרגולה על חלק מהגג המשותף באזור הנמצא מעל דירתם, התקינו תאורה וחשמל, והגביהו הגדר המקיפה את הגג באותו אזור, כל זאת מבלי שפנו קודם לכן לקבל את הסכמת בעלי הדירות האחרים (ר' חקירתו הנגדית של התובע בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 6 שורות 26-30).

בנסיבות אלו עולה כי גם התובעים ראו עצמם כבעלי זכות לשימוש ייחודי בחלק מהגג. לטענת הנתבעים במהלך 10 שנים לאחר רכישת הדירה על ידי התובעים, לא העלו טענה בנוגע לשימוש הייחודי בחצרות, והדבר לא נסתר. טענות התובעים לעניין פניות שהיו באותן שנים לעניין חלוקת הרכוש המשותף (ר' לדוגמה סעיף 32 לתצהיר התובע) לא נתמכו בכל ראיה שהיא ונראה שהם חזרו בהם מטענות אלו בחקירתם הנגדית כאשר טענו שעד שביצעו עליה בשנת 2017 ביקרו לעיתים רחוקות בדירה. בהתנהלות התובעים, בנוסף על יתר הנסיבות, יש כדי לחזק את המסקנה, שהם היו מודעים לחלוקה הנוהגת והסכימו לה. טענת התובע בחקירתו הנגדית שאמנם ידע בעת שרכש את הדירה שקיימים גדרות ושערים התוחמים את החצרות אינה עומדת בקנה אחד עם הטענה שלא היה מודע לשימוש הייחודי שעושים בעלי הדירות משום שביקר בדירה לעיתים רחוקות עד שביצע עליה בשנת 2017, וניסיונותיו להסביר את הסתירות שבטענותיו אינם משכנעים. התובע התחמק מלהשיב ישירות על שאלות בנוגע לשאלות ששאל בעת רכישת הדירה באשר לחלוקת השימושים, ובחר לחזור שוב ושוב על כך שהדבר לא היה רשום בטאבו ושלא דיבר עם השכנים (ר' עמוד 7)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 4 שורות 1-43, עמוד 5 שורות 1-13). מאידך, כאשר נשאל על המדרגות שבנו קולודני מהדירה לגג לפני שהתובע רכש את הדירה, טען שהנתבע 1 הסכים לכך בזמן שביצע את השיפוץ, שאף הוא בוצע לפני שהתובעים רכשו את דירתם (עמוד 6 שורות 45-47) כאשר מדובר בטענה שלא הועלתה על ידי הנתבעים, ואף לא על ידי התובעים בתצהירם. מכאן שלתובעים הייתה ידיעה, גם אם לאחר רכישת הדירה, על הסכמות הדדיות בין בעלי הדירות בהיבטים הנוגעים לרכוש המשותף, אולם הם בחרו להציג רק חלקים מהן כאשר עומתו עם שאלות המצביעות על ידיעתם.

מהמסמכים שצירפו התובעים לתצהירם עולה שלראשונה פנו בכתב בטענות בנוגע לשימוש הייחודי בחצרות רק 1.12.2020 (נספח 8 לתצהיר התובעים), כאשר גם אז לא טענו מפורשות לכך שלא הייתה קיימת עד לאותו מועד זכות לשימוש ייחודי כאמור, אלא שטענו שמתנהלים מגעים שנים רבות בין בעלי הדירות במסגרתם הביעו בעלי הדירות, כולל התובעים, את הסכמתם להסדיר הצמדות ושימוש ייחודי בחלקים שונים של הבית המשותף, וכי הם מעוניינים בהסדרת החלוקה והשימוש תוך הצמדת החלקים הרלוונטיים לבעלי הדירות בתקנון מוסכם. באותו מכתב, כתבו התובעים שהם מודיעים על התנגדותם לשימוש שנעשה על ידי בעלי הדירות בכל חלק של הרכוש המשותף. אציין שהתובעים לא טענו במכתב שבו הודיעו על התנגדותם, שהתנגדו גם בעבר. עניין זה מחזק את המסקנה שהתובעים לא כפרו בכך שהייתה קיימת הסכמה לעניין חלוקת השימוש, והודיעו על התנגדותם לשימוש הייחודי בחצרות לראשונה רק במועד משלוח המכתב.

38. לא נעלם מעיני שבמכתב שנשלח מטעם הנתבע 1 לעיריית ירושלים בשנת 2003 לעניין פריצת הפתח לגג שביצעו קולודני, נכתב שקולודני ביצעו פתח לגג תוך סיפוח הגג המשותף. ההסבר שניתן לכך על ידי הנתבע 1 בחקירתו הנגדית, מצביע לכל היותר על פרשנות שנתן הנתבע 1 לזכות השימוש בגג, שעה שראה בפריצת הפתח סיפוח קנייני של הגג, שלא תאם את עמדתו לעניין השימושים המותרים בגג, שכן אף שטען לעניין הפתח האמור, לא העלה כל טענה באשר לשימושים יחודיים אחרים שביצעו קולודני בגג באותה עת, כגון הצבת גדר בין החלק שלהם לחלק של הנתבעת 5 ומתיחת יריעות (עמוד 25 שורות 19-31, 45-50, עמוד 26 שורות 1-13). גם התובעים מודים ששנים לאחר מכן, לאחר שהם רכשו את דירתם, הנתבע 1 חזר ואמר להם שיש להם זכות שימוש ייחודית בגג (ר' סעיף 30 לתצהיר התובע). הדבר מחזק את טענת הנתבע 1 שלא הייתה לו כוונה לבטל את זכות השימוש הייחודית של קולודני בגג, אלא להביא לכך שכל שינוי בגג הטעון היתר בניה ייעשה בהתאם לדיון. טענת התובע שאמר בתגובה לדברים אלו שצריך לעשות הסכם מסודר, אינם מצביעים על היעדר הסכמה של התובע לכך שקיימת לו זכות לשימוש ייחודי בגג, כפי שהרושם שניסה התובע ליצור, שכן בפועל כפי שנכתב, ביצע בשנת 2020 עבודות בגג שמעל דירתו מבלי לבקש על כך רשות.

39. בנוסף, יש לציין שהנתבעים מודים כי לפחות בחלק מהתקופות, אולם לא לאחר שנת 2019, היו דודי שמש של הנתבעת 3 על גבי הגג התחתון, אף שהוסכם שיהיה בשימוש ייחודי של התובעים והנתבעת 5 וכן שלתקופה קצרה הונחו גם דודי שמש של הנתבע 2. כמו כן, הנתבעים הם ששילמו עבור זיפות הגג האמור, ואף נשלח מכתב של עו"ד מטעם "ועד הבית" ביום 25.9.2016 לנתבעת 5 (נספח 3 לתצהיר הנתבעת 5) בו נכתב שבמסגרת ההכנות לזיפות הגג נמצא שהדייר מטעמה השתלט באופן בלתי חוקי על גג הבניין המהווה רכוש משותף, שם עליו חפצים והוא מסרב לפנותם באופן המפריע לביצוע העבודות, אף שמדובר בחלק הגג לגביו הוסכם שיהיה בשימוש ייחודי של הנתבעת 5.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אף שהנתבעים פעלו לזיפות הגג והעלו טענות באשר לשימוש מטעם הנתבעת 5 בגג, אינו סבורה שיש בכך כדי לשלול את עצם קיומן של ההסכמות לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, או להביא למסקנה שהנתבעים ביקשו לבטלן. מהראיות שהוגשו, עולה שאכן החלו מחלוקות בנוגע לשימושים הייחודיים החל משנת 2016, שהביאו לטענות שונות של הצדדים זה כלפי זה, ולעיתים גם טענות שסתרו את ההסכמותיהם, אך אין בטענות אלו כדי לשנות מההסכמות שהיו ואשר נהגו בפועל במהלך שנים רבות, ואף התובעים המשיכו לנהוג על פיהן, תוך שימוש ייחודי בגג שמעל דירתם, עד להגשת התביעה ולמעשה עד היום.

באשר לנתבעת 5 – הרי שהיא עצמה חתמה על פרוטוקול האסיפה הכללית משנת 2002 לעניין חלוקת השימוש, והעובדה שהנתבעים 1-3 זיפתו על חשבונם את הגג שבשימושה הוסבר בכך שהיא לא התגוררה בדירה, אלא שוכרים מטעמה, וסרבה להשתתף בהוצאות זיפות הגג, אף שהדבר הביא לנזקים לדירות הנתבעים 1 ו-3. מכיוון שהנתבעים 1 ו-3 החליטו לזפת את הגג על חשבונם בהיעדר שיתוף פעולה מצד הנתבעת 5, הם דרשו את פינוי הגג מגרוטאות שהניח עליו שוכר הנתבעת 5. טענתם במכתב לעניין השתלטות השוכר על הרכוש המשותף (נספח 3 לתצהיר הנתבעת 5) לא נענתה, ומכל מקום העניין המרכזי של המכתב היה פינוי הפסולת לצורך זיפות הגג (ר' גם חקירת הנתבעת 3 בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 20 שורות 1-11 עמוד 22 שורות 1-4). במכלול הנסיבות נראה שלנתבעת 5 לא היה אינטרס להבהיר את זכותה באותו שלב כפי שהוסכמה על ידה בעבר לשימוש ייחודי בגג, שעה שהדבר היה כרוך בפינוי פסולת מהגג ובאיטומו, והיא העדיפה "לשבת על הגדר" כדי שלא לבצע על חשבונה את עבודות פינוי הפסולת וזיפות הגג. בנסיבות אלו אין במכתב כאמור כדי לשלול קיומו של הסכם לחלוקת השימוש.

הנתבעת 5 אף שלחה מכתב מטעמה, באמצעות עו"ד, לתובעים, ב-15.7.2020 (נספח 7 לתצהיר התובע) בו טענה כנגד הדק והפרגולה שבנו התובעים על הגג וכן טענה שאינה מסכימה לכל סיפוח חד צדדי של הרכוש המשותף, וכי הוסכם על הצדדים בדיון משותף שהדרך הראויה ולחלק את השימוש והסדרת אחוזי הבניה היא על ידי מגשר או עו"ד ולא במחטף. מכתב מאוחר זה, מטעם הנתבעת 5, נשלח בעקבות חילוקי הדעות שהחלו באותו שלב באשר לחלוקת השימושים, ואין בו כדי לשלול את קיומו של ההסכם עליו הסכימה הנתבעת 5 שנים קודם לכן. יתר על כן, בכל הנוגע לתובעים, הרי שעולה מהמכתב שאף שהנתבעת 5 טענה כלפיהם באשר לשימוש ייחודי שהם עושים בגג, הם לא פעלו לפירוק הדק או הפרגולה, וכן הם לא הציגו כל מכתב שניתן במענה לטענות אלו.

בנוסף, אין בעובדה שהייתה קיימת צנרת משותפת על גבי הגג כדי לשלול הסכמה לשימוש ייחודי, כפי שצנרת כאמור יכולה לעבור גם בשטח פרטי של מי מבעלי הדירות (ר' הגדרת רכוש משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין). מהעדויות עלה שגם בחצרות שנמצאות בשימוש הנתבעים עובר רכוש משותף, ואף שהיו תקופות שהיה בהן רכוש פרטי של בעל דירה אחרת (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022, עמוד 19 שורות 43-33 עמוד 22 שורות 11-20).

באשר לדודי השמש, עלה מהעדויות שעל הגג שמעל דירת התובעים היו 2 דודים בלבד, האחד שלהם והשני של הנתבעת 3 ועל הגג העליון היה דוד של הנתבע 2 (ר' חקירתו הנגדית של הנתבע 1 פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 24 שורות 7-3) כאשר לתקופה קצרה הדו של הנתבע 2 הורד לצורך ביצוע תיקונים לגג שמעל דירת התובעים (ר' חקירת הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2 עמוד 12 שורות 5-15, חקירת הנתבע 1 שנתן גרסה יותר מדויקת באשר לתקופה שבה היה דוד הנתבע 2 על הגג התחתון בעמוד 24 שורות 1-11). כן עולה שבשנת 2016 אכן הוחלט להעלות את הדודים מהגג התחתון לגג העליון, לקראת ביצוע זיפות של הגג (עמוד 24 שורות 1-3) כאשר הסיבה להעלאת הדוד של הנתבעת 3 (שהיה הדוד היחיד חוץ מדוד התובעים שהיה על הגג התחתון באותה עת) לגג העליון, היה דרישת התובעים (ר' חקירת הנתבעת 3 בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 18 שורות 2-11), ועל כן ניתן להבין שהונחו שם כל עוד לא הייתה טענה שהדבר מפריע לשימוש הייחודי של התובעים בגג, אולם עצם העובדה שהנתבעת 3 נדרשה להעלות את הדוד לגג העליון תומכת במסקנה שהן היא והן התובעים ראו באותו חלק של הגג שעליו היה מוצב הדוד, כחלק של תובעים יש זכות שימוש בו.

בפרוטוקול אסיפת הדיירים מתאריך 3.5.2018 (נספח 12 לתצהיר הנתבע 1) נכתב באשר לשימוש ברכוש המשותף, שנכון לאותו מועד הנתבעים 1-3 משתמשים בגינות הצמודות לדירותיהם וכי אין התנגדות שהתובעים והנתבעת 5 ישתמשו בגג שמעל לדירותיהם כמרפסות מגוננות.

תחילה אציין שאין בשימוש בפרוטוקול במונח "רכוש משותף" לחצרות האמורות כדי לסייע לתובעים בטענותיהם, שכן מבחינה קניינית אכן מדובר ברכוש משותף, והשאלה היא האם קיימת הסכמה לחלוקת השימוש בו.

גם אם עולה לכאורה כאילו מדובר בהסכמה חדשה לשימוש התובעים והנתבעת 5 בגג, יש לקרוא את הדברים על רקע חילוקי הדעות שהחלו בין הצדדים לעניין הרישום הקנייני של הזכויות, בעקבותיהם ככל הנראה נעשה ניסיון על ידי הנתבע 1 שניסח את הפרוטוקול, לכתוב את הדברים בצורה שתעורר כמה שפחות התנגדות. מכל מקום, התובעים לא טענו שהתנגדו לאמור בפרוטוקול, אולם עולה שהנתבעת 5, באמצעות בתה, ביקשה להוסיף לו שורה על פיה "הוסכם כי הדיון בנוגע לשימוש בשטחי הרכוש המשותף ידון לאחר ביצוע עבודות ניקיון וזיפות הגג" (סעיף 41 לתצהיר בתה של הנתבעת 5). מחקירתה של בת הנתבעת 5 עלה שהייתה מודעת כבר אז לחלוקת השימוש, דבר שהיה מוסכם על אמה בחתימתה על פרוטוקול האסיפה משנת 2002, אולם חלקה בעיקר על האופן בו בוצעו הגדרות והשערים, ונתנה פרשנות לא לגמרי ברורה לשימוש האמור – על פיה מחד זכאים בעלי הדירות הרלוונטיות לעשות גינות ולשים מתקנים בחצרות הסמוכות לדירתם, ולהמשיך את השימוש שהיה בפועל במהלך השנים, ומאידך יש לאפשר לה להיכנס לאותן חצרות (ר' חקירתה הנגדית של הנתבעת 5 בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 33 שורות 11-25 עמוד 34 שורות 28-40). הנתבעת 3 טענה שהסתייגות הנתבעת 5 התייחסה לסוגי השימושים שניתן יהיה לבצע במסגרת השימוש הייחודי הקיים, דבר שלא רחוק מדברי בת הנתבעת 5 (ר' עמוד 19 שורות 4-29). הנתבע 1 שכתב את הפרוטוקול, פירש את האמור כך שיוכל להתקיים דיון בנושא, אבל שדיון כאמור אינו גורע מהמצב הקיים (עמוד 27 שורות 15-19). מכל מקום, אין מחלוקת שהנתבעת 5 חתמה על פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 1.5.2002 וסעיף 6 לאותו פרוטוקול המתייחס לחלוקת השימוש ברכוש המשותף הוא מפורט וברור, ואינו עומד בקנה אחד עם הפרשנות המעורפלת של בת הנתבעת 5 בעדותה. על כן, גם אם נכתב ניסוח מעורפל יותר בפרוטוקול משנת 2018, שכל אחד מבעלי הדירות נתן לו פרשנות משלו, אין בכך כדי לבטל את חלוקת השימוש כפי שהייתה בפועל, מה גם שהתובעים עצמם פעלו לאחר מכן כמי שיש להם זכות לשימוש ייחודי בגג, כאשר בנו בשנת 2020 פרגולה ודק על הגג, וביצעו בו שינויים נוספים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למעשה, העולה מהתנהלויות אלו של הצדדים החל משנת 2016, שאכן מאותו מועד החלו מגעים בין בעלי הדירות בין היתר לאור דרישת התובעים לחלוקה קניינית של הזכויות ברכוש המשותף, דבר שהביא לטענות שונות של הצדדים, זה כלפי זה, בעניינים הקשורים באותו שימוש. אולם גם אם עולה שהייתה נכונות לכל בעלי הדירות לדבר על עיגון קנייני של הזכויות ברכוש המשותף, ואף בנוגע לזכויות הבניה, לכל היותר עולה כי הטענות נגעו לשינוי אופי השימוש הייחודי על ידי מי מבעלי הדירות, שהיה ידוע והיו לו ביטויים ברורים בשטח, אך עד למכתב התובעים מיום 1.12.2020 לא דובר על ביטול ההסכמות.

באשר לעובדה המוסכמת שלכל בעלי הדירות היה במהלך השנים מפתח לגג, הדבר מתיישב עם העובדה שהיו להם דודי שמש על הגג, אשר אין מחלוקת שכעת נמצאים על הגג העליון, ועל כן נדרשו למפתח כדי לטפל בדודים בעת הצורך. אין בכך להצביע על שימוש שנעשה מטעם הנתבעים 1-3 בגג שמעל דירות התובעים או הנתבעת 5.

40. מכל האמור לעיל ניתן ללמוד על הסכם שנהג בין בעלי הדירות בבית המשותף לחלוקת השטחים המשותפים באופן שהנתבעים 1-3 רשאים לעשות שימוש ייחודי בחצרות הסמוכות לדירותיהם, ואילו התובעים והנתבעת 5 רשאים לעשות שימוש ייחודי בשטח הגג, כל אחד באופן יחסי לשטח דירתו. אמנם עולה כי היו במהלך השנים חילוקי דעות בהיבטים שונים של ההסדר, כגון לעניין השאלה האם ניתן לפרוץ במסגרתו פתח לגג, או לבצע שינויים אחרים הטעונים היתר בניה, האם הוא מאפשר הצבת מתקנים משותפים או כאלו השייכים לדירה אחת בשטח שבשימוש דירה אחרת, אבל עד לפניית התובעים בשנת 2020 לא הייתה מחלוקת על עצם קיומה של הסכמה לחלוקת השימוש. כן עולה כי ההסכם האמור, אשר נהג עוד לפני שהתובעים רכשו את דירתם, היה מקובל גם על התובעים, אשר היו מודעים בעת רכישת דירתם לקיומם של הגדרות והשערים התוחמים את החצרות שבשימוש הנתבעים 1-3, וכלל לא ניסו להיכנס לאותן חצרות, היו מודעים לכך שיש מדרגות ופתח מדירתם לגג שמעליה, ואף נהגו בפועל על פי ההסכמה האמורה בכך שבנו, מבלי שביקשו קודם לכן את הסכמת בעלי הדירות, דק ופרגולה על גבי הגג, הציבו ארון, והגביהו את הגדר התוחמת חלק מהגג.

האם ההסכם ניתן לביטול?

41. ככלל, בעל דירה רשאי לבטל בכל עת זכות שימוש ברכוש המשותף שנתן לבעל דירה אחרת [ר' לדוגמה ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא (3) 210, (1977) וכן ע"א 17397-02-19 (מחוזי ת"א) **חסידים ואח' נ' נציגות הבית המשותף ואח'** (נבו 1.4.20)], אולם אם בעל דירה נתן הסכמה מפורשת, לא תתאפשר לו חזרה מהסכמתו אם קיימת מניעות לכך מטעמי צדק [עניין **כליפא** לעיל וכן ע"א 19/81 **ביבי נ' הוברט** פ"ד לז(2) 497; ע"א 31/70 **כהן נ' שמאי** פ"ד כ(2) 388].

42. במקרים חריגים, לא תתאפשר לבעל דירה חזרה מהסכמתו אף אם זו אינה מפורשת, וזאת משיקולי צדק, כאשר אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, וכאשר בהסתמך על מתן הרישיון, נוצרה צפייה לגיטימית אצל בעל הרישיון כי הרשות ניתנה לצמיתות. דברים אלו נלמדים מהפסיקה העוסקת במוסד ה"רישיון במקרקעין" בנוגע למצבים שבהם שיקולי צדק מביאים למסקנה שאין מקום לביטול רישיון כזה [ר' נינה זלצמן **"רישיון במקרקעין"** הפרקליט מב, 24-63 (תשנ"ה); ע"א 7139/99 **אלוני נ' ארד** פ"ד נח(4), 27;]



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419 (1995); ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ
נחמה פ"ד מו(5) 184 (1992); ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321 (1986); ע"א
515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (נבו 8.11.2012).

43. באשר לסוג השיקולים הנלקחים בחשבון, יפים הדברים שנאמרו בעמ"ש 5174-09-15
(מחוזי מרכז) א.ג ואח' נ. א.מ ואח' (נבו 19.2.17) בפסקה 40:

"באשר לשיקולים אותם יבחן בית המשפט לצורך קביעה האם מדובר ברישיון
בלתי הדיר נקבע בפסיקה כי על ביהמ"ש לבחון, בין השאר, את כוונת הצדדים
ליצירת רישיון, תנאי הרישיון, משך הזמן בו החזיק בעל הרישיון בקרקע בלי שפעל
בעליה לסילוקו; כמו כן תבחן השאלה האם בהסתמך על ציפייה זו השקיע בעל
הרישיון השקעות בנכס, כגון הקמת מבנה או שיפור מבנה קיים, ומה היקף
ההשקעות; האם ההשקעות היו על דעת בעל המקרקעין ובשיתוף פעולה עמו
וכיוצ"ב (ע"א 463/79 הנ"ל; ע"א 2836/90 הנ"ל; רע"א 2701/95 כנען נ' אלטיף,
[פורסם בנבו] (1999); תמ"ש (משפחה יר') 11900/98 ד' נ' א' [פורסם בנבו]
(2007); תמ"ש (משפחה קר') 4141/02 פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו] (2009))."

44. שיקולים דומים נלקחים בחשבון גם בבחינת הנסיבות שבהן בעל דירה, ואף חליפו, חוזר
מההסכמה, שעה שעולה שבין בעלי הדירות נוצר הסכם לחלוקת השימוש הייחודי ברכוש
המשותף. קיומו של הסכם כאמור, מניח שאין מדובר ברישיון חניס, אלא בויתור הדדי של
בעלי הדירות זה כלפי זה, לטובת שימוש ייחודי של כל אחד מהם בחלקים מהרכוש
המשותף. גם במקרה כזה יש רלוונטיות לשיקולי צדק ובכלל זאת לאופן בו בעל הדירה
שדורש הפסקת השימוש הייחודי התנהל, והאם התנהלותו עולה בקנה אחד עם חובת תום
הלב. לעניין זה יפים הדברים שנכתבו על ידי כב' השופט ט' חבקין ת"א (שלום תל אביב)
34217-12-18 אבידן נ' דנציג (נבו 15.8.2022) בפסקה 30:

"הזכות לבטל הסכם שיתוף מכללא צריכה אפוא לעלות בקנה אחד עם החובה
לקיים הסכם בתום לב המעוגנת בסעיף 39 לחוק החוזים. עם זאת, על הסכם
שיתוף מכללא אין לומר, בדרך כלל, שהוא בלתי הדיר ולכן אינו ניתן לביטול. יש
להכיר בזכות לבטל הסכם כזה בהתראה סבירה מראש במקרים שבהם תוכן
ההסכם או שינוי נסיבות מאוחר לו מגבשים חלוקה לא שוויונית ולא הוגנת של
השימוש הייחודי ברכוש המשותף. שימוש בזכות לבטל הסכם שיתוף מכללא
מצריך אפוא לאזן בין זכויות הצדדים והאינטרסים המתחרים. מחד גיסא, זכותו
הקניינית של בעל דירה להסתמך על המרשם ולהשתמש באופן סביר בחלקו הבלתי
מסוים ברכוש המשותף; מאידך גיסא, יש ליתן משקל להסתמכות ארוכת שנים
על המצב בפועל ועל החובה לפעול בתום לב בקיום הסכם, ובלבד שחלוקת השימוש
היא הוגנת ושוויונית ושכלול הנסיבות מטה את הכף להותירה על כנה ולהגן
עליה. בכלל זה יש לבחון מה ידע או צריך היה לדעת בעל הדירה שמבקש לבטל את
ההסכם על אודות המצב הנוהג בפועל; אם הסכם שיתוף שנערך עם קודמיו (לרבות
בהתנהגות) היה ידוע לו ומחייב אותו כחליף; אם בירר אם יש בנמצא הסכם שיתוף
לפני שביקש לשנות מהמצב הקיים. בהקשר זה נפסק כי מוטל על רוכש מקרקעין
נטל לברר אם יש בנמצא הסכם שיתוף שעה שנעשה שימוש ייחודי במקרקעין
שרשומים בבעלות משותפת או כרכוש משותף, ואם לא בירר הסכם שיתוף שלא
נרשם עלול לחייבו. מנגד, אם לא ידע ולא היה עליו לדעת שיש בנמצא הסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/377/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיתוף, ההסכם לא יחייבו ([ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון](#), פסקות 46-47 [פורסם בנבו] 9.8.2017); [ת"א \(שלום ת"א\) 55738-04-19 מובשוביץ נ' ארביב](#) [פורסם בנבו] 8.8.2022). מסגרת נורמטיבית זו טעונה יישום בענייננו.

45. גם בפסיקה הקיימת של מפקחים על רישום מקרקעין, נמצא במקרים מתאימים שבעל דירה אינו רשאי לחזור בו מהסכמות כאמור לחלוקת השימוש ברכוש המשותף. השיקולים המרכזיים שלא להתיר חזרה כאמור נוגעים לתמורה שנתנה בשל השימוש הייחודי, הסתמכות מי שקיבל זכות לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף ושינוי מצבו לרעה, ומשך הזמן בו מתקיים השימוש הייחודי מבלי שנטען כלפיו. כן נמצא שהסכמות כאמור מחייבות גם אם השטחים בו קיבלו בעלי הדירות שימוש ייחודי אינם זהים לחלוטין בגודלם [ר' לדוגמה תיק (מפקח על רישום מקרקעין חיפה) 428/16 שחם נ' אזולאי (נבו) 19.3.2017]; תיק (מפקח על רישום מקרקעין ירושלים) 498/16 שנהב נ' מורלי (נבו) 17.5.2020]; תיק (מפקח על רישום מקרקעין ירושלים) 227/11 אדלמן נ' אלון (נבו) 11.4.2013].

46. באשר למשך השנים בו נעשה השימוש הייחודי, הרי שעולה שמדובר בעשרות שנים. התובעים מצדם רכשו את דירתם רק בשנת 2007 ואינם יכולים להעיד על המצב שקדם לכך. כעולה מהפסיקה שהובאה לעיל, העובדה שלא ביררו, לטענתם, בעת רכישת דירתם האם קיים הסכם בין בעלי הדירות, למרות שהמצב בשטח העיד על חלוקת השימוש, עומדת לחובתם. כמו כן התובעים מצדם בחרו שלא לזמן את קולודני, ממנו רכשו את דירתם, לתת עדות בעניין, אף שעולה ששוחחו עמו בנוגע להליך דנן (ר' דברי התובע בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2023 עמוד 8 שורות 13-24). עניין זה אף הוא עומד לחובתם של התובעים, ומחליש את טענותיהם. מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 1.5.2002 עולה כי השימוש הייחודי היה קיים עוד קודם לאסיפה האמורה, ועל פי ראיות התובעים מדובר בעשרות שנים קודם לכן. גם התנהלות קולודני בבניית מדרגות מדירתו לגג, ומחתימתו על ההסכם מול הנתבעת 3 בשנת 1989 לעניין שימוש ייחודי שלה בחצר ושלו בגג, מצביעה על הסכמתו לכך.

47. באשר להסתמכות הנתבעים על ההסכם, מראיות התובעים עולה כי לפחות חלק מהגדרות נבנו או חוזקו כחלק מהעבודות שבוצעו על ידי הנתבע 1, בשל המצב הקודם, המוזנח, של הבית המשותף (ר' סעיפים 7, 20, 26 ו-27 לתצהיר הנתבע 1 אשר לא נסתרו).

אמנם קולודני לא הסכים לעבודות כאמור, ואף הגיש התנגדויות לוועדות התכנון, אולם טענותיו נדחו בין היתר משום שלנתבע 1 היה הרוב הקנייני הדרוש להרחבת דירתו. כמו כן, יתר בעלי הדירות, מלבד קולודני, הסכימו כאמור לביצוע העבודות ברכוש המשותף. הסכמה כאמור, של רוב בעלי הדירות באשר לביצוע עבודות ברכוש המשותף, מחייבת גם בעל דירה שהתנגד לה, אם כי לא ניתן לחייבו בעלויות הכרוכות בכך, ככל שאינן נובעות מהחוק או מהתקנון (סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין). בהיבט זה, המניעות שנוצרה כלפי קולודני בנוגע לביצוע העבודות, מחייבת גם את התובעים שנכנסו בנעליו [ר' [ע"א 402/80 אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א.](#) החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309, 320 (1981)].

השקעות משמעותיות אלו, שבוצעו על ידי הנתבע 1, בוצעו על בסיס ההסכם שנהג לעניין חלוקת השימושים, ולא בכדי ניתן לו ביטוי בפרוטוקול האסיפה כללית לעניין ההחלטה על ביצוע העבודות מיום 1.5.2002. יש לראות גם את הנתבעים 2-3, שהסכימו לעבודות שבוצעו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על ידי הנתבע 1 בתמורה להרחבת דירתו, כמי שהיו שותפים לאותן השקעות. מכאן שהנתבעים 1-3, באמצעות הנתבע 1, השקיעו כספים רבים בבניית קירות התמך, השערים חלק מהגדרות ומפלסי המעבר לחצרות הנתבעים 1 ו-2 על בסיס ההסכם האמור.

48. בנוסף, חצרות הנתבעים הן חצרות מטופחות שהושקעו בהן משאבים, כגון לבניית גדר וטיפוח גינה (חצר הנתבעת 3) בניית 2 פרגולות וגדר (חצר הנתבע 2) וריצוף מעוצב (חצר הנתבע 1) כפי שהתרשמתי במסגרת ביקורי במקום וכפי שעלה מתצהירי הנתבעים ולא נסתר, כך לדוגמה מסעיף 7 לתצהיר הנתבע 2 עולה שריצף חלק משטח הגינה, הניח דשא סינטטי, שתל צמחים, בנה פרגולה, התקין ספסלים ועוד, וכן מסעיף 5 לתצהיר הנתבעת 3 ממנו עולה שריצפה חלק משטח הגינה, התקינה מעקה, תאורה, מילאה באדמה ושתלה צמחים רבים התקינה מערכת השקיה ועוד. הנתבע 1, כעולה מסעיף 27 לתצהירו, השקיע סכומים ניכרים בשיפוץ הגינה במסגרת עבודות השיפוץ שעשה בשנת 2005, ובכלל זאת חפר ורוקן עשרות מטרים מעוקבים של אדמה, יצק רצפת בטון, ריצף את השטח בנה מדרגות, נטע שתילים ועוד. גם מחוות הדעת שהוגשה על ידי שמאית מטעם התובעים עולה שמדובר בגינות מטופחות (ר' לדוגמה עמוד 8 לחוות הדעת וכן התמונות שצורפו לה).

49. באשר לגודל השטחים בהם קיים שימוש ייחודי, אמנם עולה כי לא מדובר בשטחים זהים בגודלם, כאשר לנתבעים 2 ו-3 חצרות גדולות יחסית, ששטחן גדול משטח דירותיהם, לנתבע 1 חצר קטנה, ששטחה קטן משטח דירתו אף במצב שקדם להרחבת דירתו, וכן לתובעים ולנתבעת 5 שטח גג שגודלו זהה פחות או יותר לשטח דירתם הנמצאת מתחתיו. עניין זה נובע מהמבנה הייחודי של הבית המשותף, ומכך שקיימים הפרשי גובה משמעותיים בין החצרות, כך שהגישה מהדירות לחצר הנמצאת בשימוש דירה אחרת אינה נוחה. כך לדוגמה, כדי להגיע לחצר שבשימוש דירת הנתבעת 3, יש לרדת תחילה מספר מדרגות לכיוון החצר שבשימוש הנתבע 1 ואז לעלות מדרגות רבות, כאשר הגישה הנוחה לחצר זו היא מתוך דירת הנתבעת 3. הגישה לחצר שבשימוש דירת הנתבע 2, כפי שהייתה שנים רבות (על פי סעיף 4 לתצהירו, כמעט 60 שנה, מאז שרכש את הדירה), היא מכניסה נפרדת ברחוב ולא מהשביל המוביל לכניסה לבית המשותף.

בנוסף, מבחינת חלקם היחסי של בעלי הדירות ברכוש המשותף, עולה כי היחס בין שטח הגג שבשימוש התובעים ביחס לכלל השטחים המשותפים שבשימוש ייחודי של בעלי הדירות, קטן רק במעט מחלקם היחסי ברכוש המשותף. חלקם של התובעים ברכוש המשותף על פי נסח הרישום הוא 97/426, דהיינו, 0.23. מסמכי הרישום אינם כוללים את שטחי החצרות, ועל כן בחנתי עניין זה על פי מפת מדידה שצורפה כנספח 4 לתצהיר הנתבע 1, במסגרתה נמדדו השטחים ברוטו. גם אם לא מדובר במידות מדויקות, יש בהן כדי להראות בקירוב את היחס בין השטחים. על פי המפה האמורה שטח דירת התובעים הוא 110 מ"ר ברוטו, וזהו גם שטח הגג שמעליה, מתוך שטח כולל של הדירות שמתחת לגג שהוא 194 מ"ר ברוטו. שטח הגינות שבשימוש ייחודי הוא 399 מ"ר (אציין כי שטח הגינות כפי שצוין בחוות הדעת השמאית מטעם התובעים קטן יותר, כך שכל הנראה גם אם המידות שבמפת המדידה אינן מדויקות, הדבר פועל לטובת התובעים). סה"כ השטח המשותף שבשימוש ייחודי הוא 593 מ"ר, כך שהחלק היחסי של התובעים הוא 110/593, דהיינו 0.19. יובהר כי חלקם של התובעים ברכוש המשותף על פי נסח הרישום מתייחס למצב שקדם להרחבת דירת הנתבע 1, דהיינו, חלקם היחסי גדול יותר לעומת המצב החדש שנוצר לאחר הרחבת דירת הנתבע 1, אשר טרם ניתן לו ביטוי רישומי. מכאן שאף שלא מדובר בחלוקה שוויונית של השטחים המשותפים (כאשר חלקו של הנתבע 1 הוא הקטן ביותר ביחס לחלקו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ברכוש המשותף, אולם הוא אינו מבקש לבטל את חלוקת השימוש. אציין שבניגוד לנטען על ידי התובעים והנתבעת 5, שטענו שבשימושם גם חלק מהגינה הצפונית – הדבר עומד בניגוד למה שנצפה במסגרת הביקור במקום), הרי שהתובעים לא קופחו במידה כזו המייצרת חוסר הוגנות.

טענות התובעים בסיכומיהם לכך שהשימוש בגינות בעל ערך גבוה יותר מהשימוש בגגות נטענו בכלליות ולא הוכחו.

50. בשולי הדברים אוסיף שאף שמצאתי שאין מקום לביטול ההסכמות, אין בכך כדי להביא למסקנה שלא ניתן להציב מתקנים משותפים ואף מתקנים פרטיים של מי מבעלי הדירות בחצרות או בגגות, גם אם אלו בשימוש ייחודי של בעל דירה אחר, ככל שנמצא שבשל אופיים של המתקנים המקום המתאים ביותר להצבתם הוא בחצר או בגג הנמצא בשימוש ייחודי כאמור, ולא מתאים להציבם בחלק הנמצא בשימוש ייחודי של בעל המתקן או באזור אחר ברכוש המשותף. עניין זה נלמד מכך שעלה מהראיות שגם כיום נמצאים מתקנים משותפים הן בחצרות והן על הגג, וכן מכך שגם בעבר הוצבו מתקנים פרטיים של מי מבעלי הדירות בשטח שהוסכם שהוא בשימוש ייחודי של אחרים – כך לדוגמה דוד השמש של הנתבעת 3 שהיה מוצב על הגג שבשימוש התובעים, או מתקן הסולר של הנתבעת 5 שהיה מוצב בחצר שבשימוש הנתבעת 3 (פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 22 שורות 11-20).

דרישת התובעים להריסת קירות ושערים

51. דרישתם של התובעים להריסת גדרות ושערים נדחית כפי שיפורט להלן.

52. ראשית, אין מחלוקת שהגדרות והשערים היו קיימים לפני שהתובעים רכשו את דירתם. חלקם היו קיימים לפני השיפוץ שבוצע בשנת 2005 על ידי הנתבע 1, וחלקם נוספו או תוקנו במסגרת השיפוץ. בעלי הדירות רשאים להחליט בהסכמת הרוב על שינויים ברכוש המשותף ואופן ניהולו. יתר על כן, על פי סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין**, החל על הבית המשותף דן, ניתן לבצע על פי החלטת האסיפה הכללית, לא רק שינויים המיטיבים עם הרכוש המשותף בהחלטת רוב בעלי הדירות, אלא אף כאלו הפוגעים בו ומשנים את חזות הבית המשותף כפי שהייתה בעת גמר הבניה. בענייננו, החלטת בעלי הדירות לעניין השיפוץ ולעניין הכולל שינויים ברכוש המשותף נתנה ברוב הדרוש לכך, שכן כל בעלי הדירות חתמו על הסכמתם לביצוע השינויים למעט קולודני. לפיכך, וכפי שנאמר לעיל, היא מחייבת גם את התובעים שרכשו את דירתם לאחר מכן.

53. שנית, התובעים לא הבהירו, לכל הפחות בנוגע לגדרות, מהם הגדרות שהם דורשים את הריסתן, כאשר עלה שלכל הפחות הריסת חלק מהגדרות תפגע ברכוש המשותף (רי' לדוגמה סעיף 46 לתצהיר התובע בו קיימת התייחסות כללית לגדרות פנימיות ודברי התובעת בחקירתה הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 11 שורות 3-10 וכן התייחסות כללית לגדרות ושערים בחוות הדעת השמאית מטעם התובעים). אציין שמביקורי במקום עלה כי לפחות חלק מהגדרות הן קירות גבוהים המפרידים בין חצרות במפלסים שונים, שגם ממבט לא מקצועי עולה שאין כל הגיון להורסם, שכן הדבר יביא לקריסת החצר העליונה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

54. שלישית, הן השערים והן הגדרות נועדו בין היתר לתחום את השימוש הייחודי בהתאם להסכם שבין הצדדים, אשר כפי שנמצא לעיל, הוא בלתי הדיר. בבנייתם הושקעו כספים, על בסיס אותן הסכמות. מחקירתו של התובע עולה כי הסיבה לדרישה זו היא כדי לאפשר גישה חופשית לשטחי החצרות (פרוטוקול הדיון מיום 25.10.2022 עמוד 8 שורות 36-42). משנמצא שאין מקום לאפשר גישה חופשית לחצרות, הרי שנשטם הבסיס להריסתם.

מבנה העזר שבחצר הסמוכה לדירת הנתבעת 3

55. מדובר במבנה שקיים לכל הפחות משנת 1976 כעולה מתצלום אוויר שצורף כנספח 2 לתצהיר הנתבע 1, המבנה נמצא בחצר שבשימוש הנתבעת 3, ומשמש כסטודיו, אשר הנתבעת 3 הגיעה ששופץ במהלך השנים. התובעים לא טענו, וממילא לא הוכחו, שהמבנה האמור היה בשלב כלשהו בשימוש של מי מבעלי הדירות מלבד הנתבעת 3. בנוסף, לא נטען וממילא לא הוכח כי בשלב כלשהו טרם הגשת התביעה נערכה פניה לנתבעת 3 בדרישה להרוס אותו, ומטענת התובעים עולה שדרשו הריסתו מכיוון שלטענתם הוא מונע שימוש סביר שלהם בחצר האמורה. מכיוון שנמצא שההסכם בין בעלי הדירות לחלוקת השימוש ברכוש המשותף התייחס גם לחצר האמורה, ומכיוון שההסכם לא החרג את המבנה האמור אף שמוכן שבעלי הדירות היו מודעים לקיומו ולשימוש הייחודי שעושה בו הנתבעת 3, הרי שניתן לראות את ההסכמות לעניין חלוקת השימוש הייחודי כמתייחסות גם לשימוש הייחודי של הנתבעת 3 במבנה האמור.

56. בנסיבות אלו, כאשר נמצא שאין מניעה להמשך השימוש הייחודי של הנתבעת 3 בחצר הסמוכה לדירתה, הרי שלאור משך השנים בהן קיים המבנה מבלי שמי מבעלי הדירות ביקש לפרקו, ולאור ההשקעות שהושקעו בו, איני מוצאת מקום להורות על הריסתו.

57. טענות נוספות לעבירות בניה שבוצעו לכאורה על ידי הנתבעת 3, לרבות טענות בדבר הרחבת דירה על חשבון שטחים משותפים, לא נטענו בכתב התביעה, ומהוות הרחבת חזית ועל כן יימחקו. יובהר כי בכל הנוגע לטענות בהיבטים תכנוניים, הרי שעניינים אלו אינם בסמכות ערכאה זו.

סיום

58. לאור כל האמור, התביעה נדחית. לאור האמור על התובעים לשאת בהוצאות הנתבעים 1-3, אולם לא בהוצאות הנתבעת 5 אשר תמכה בטענותיה בסעדים שהתבקשו על ידי התובעים, ועל כן גם טענותיה נדחו. לפיכך אני קובעת שעל התובעים לשלם לנתבעים 1-3 הוצאותיהם בסך של 15,000 ₪.

ניתן היום, י"ח אלול תשפ"ג, 04 ספטמבר 2023, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/377/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים**